InDret

Codificació civil i competència legislativa de la Generalitat de Catalunya

Joan Egea Fernàndez
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper de Dret Català núm: 8
Barcelona, octubre de 2003
www.indret.com

Abstract

La Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya, és la manifestació més clara de la voluntat del Parlament de Catalunya de culminar, al nivell més alt possible, el procés de desenvolupament del dret civil català. A això s'hi ha oposat el govern de l'Estat amb la interposició, el passat 10 d'abril de 2003, d'un recurs d'inconstitucionalitat contra l'esmentada Llei. El recurs qüestiona la constitucionalitat de la tècnica d'un codi civil per a Catalunya basant-se en l'atribució d'una funció gairebé constitucional al Código civil espanyol com a limitador de les competències de la Generalitat. En aquest treball se sosté, per contra, que la Constitució en cap cas no reconeix aquest paper al Código i que l'opció codificadora, en si mateixa considerada, no pot esdevenir inconstitucional ja que una mera tècnica legislativa, en principi, no pot envair les competències que l'art. 149.1.8a CE reserva 'en tot cas' a l'Estat.

Sumari

1. El Codi civil de Catalunya: seguretat jurídica, simplificació normativa i reputació
2. El recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya: l'anacronisme de fonamentar la interpretació de l'art. 148.1.8a CE en els postulats decimonònics de la unificació civil
3. La jurisprudència del Tribunal Constitucional
4. Constitucionalitat de la Primera Llei del Codi civil de Catalunya

1. El Codi civil de Catalunya: seguretat jurídica, simplificació normativa i reputació

El 13 de gener de 2002, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 3798) publicava la *Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya,* que dissenya l'estructura, el contingut i el procediment de tramitació del Codi, a l'hora que n'aprova el Llibre primer. Amb l'adopció de la tècnica d'un codi general, el Parlament dóna un pas molt important cap a l'equiparació de l'ordenament civil català amb els del seu entorn i abandona la via de la codificació sectorial que, no fa massa, va conduir als codis de successions i de família, tot descartant completar la triada amb el Codi de dret patrimonial. De fet, el passat 23 de juny, el govern de la Generalitat ja va acordar presentar al Parlament el projecte de Segona Llei del Codi civil de Catalunya relatiu al Llibre cinquè, sobre els drets reals (BOPC núm. 451, de 30 de juliol), tot i que, hores d'ara, en haver-se publicat ja el Decret de dissolució del Parlament i de convocatòria d'eleccions pel proper 16 de novembre, aquesta iniciativa ha quedat en un mer gest.

> Malgrat que alguns autors (ROCA SASTRE , *Estudios de derecho civil especial de Cataluña.* Barcelona, 1983, pàg. 1) haguessin considerat que la Compilació del Dret Civil Especial de Catalunya de 1960 participava de la naturalesa dels codis perquè, apartant-se de la tècnica recopiladora, adoptava un esquema molt semblant a la del propi Codi espanyol, és extremadament forçat afirmar que ho fos. Efectivament, fins i tot deixant de banda el seu propi nom i prescindint també de que, d'acord amb *Decreto de 23 de mayo de 1947, por el cual se crean las Comisiones de juristas para el estudio y la ordenación de los derechos forales*, les compilacions havien de ser el primer pas cap un codi únic per a tota Espanya, el cert és que aquella Compilació no anava més enllà d'una mera agrupació incompleta de les antigues lleis simplificades i sistematitzades, i que quedava molt lluny dels autèntics codis. És més, en la seva tramitació parlamentària, el text va ser dràsticament retallat per les corts franquistes, cosa que en el preàmbul es justifica dient que *"[n]o ha recogido algunas normas vigentes en Cataluña, que presentaban ligeras variantes* [referint-se al Código civil]*"*. Igualment, el fet que partís de que *"[l]a especialidad es la nota característica de estas Compilaciones, sin que, por tanto, sean aconsejables enmiendas a la Ley común"*, deixava clar que no pretenia ser un codi en sentit propi; la llei comuna ho seguia sent el Codi civil espanyol, del qual la Compilació n'era només una simple especialitat a l'espera d'aquell anunciat codi general per a tota Espanya, que ja mai arribaria.

Si exceptuem el curt parèntesi de la Segona República, no va ser fins la Constitució de 1978 i el subsegüent Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979 que no es va fixar un nou marc normatiu que, en l'àmbit civil, possibilità que Catalunya recuperés la capacitat legislativa perduda al segle XVIII amb la derrota en front de les tropes de Felip V. La tècnica legislativa emprada al llarg d'aquests més de vint-i-cinc anys d'autonomia legislativa ha estat força heterogènia: inicialment, s'optà per les lleis especials, combinades amb les de reforma de la Compilació; després, sense abandonar del tot les lleis especials, es passà a la codificació sectorial dels tres grans blocs del dret civil: successions, família i patrimonial; i ara, descartat el Codi de dret patrimonial, s'ha endegat directament la via del Codi civil de Catalunya. Val a dir, però, que en l'horitzó del legislador català ben aviat es va dibuixar l'objectiu de que tota aquella legislació dispersa i també els Codis sectorials eren meres eines que havien de facilitar el trànsit cap a un Codi civil de Catalunya. Aquest, finalment, s'ha concebut com a un **codi obert**, que s'ha d'anar confegint mitjançant successives lleis seriades, amb la qual cosa es facilita donar una resposta més àgil als canvis socials que inevitablement es van produint, bé sigui mitjançant la seva reforma o bé incorporant institucions encara no regulades, sense forçar-ne la seva estructura ni la sistemàtica.

Des d'aquesta perspectiva, és prou clar que el Codi civil de Catalunya, com la resta de codis moderns, desenvolupa una funció que no té massa a veure amb la codificació decimonònica, ja que avui en dia la tècnica codificadora no s'ha de considerar com a un instrument que contribueixi de forma determinant a la modernització de les estructures socials i econòmiques, sinó que aquest és un paper que, en les seves línies fonamentals, el desenvolupen les modernes constitucions. Efectivament, ni, en el seu moment, els codis de família i de successions, ni ara tampoc el Codi civil de Catalunya no responen a la concepció político-filosòfica dels codis del segle XIX, sinó que estan més a prop de les anomenades *lleis consolidadores* (N. IRTI, 1986, 2a, 59), en el sentit que tots els sistemes jurídics, grans o petits, estan regits per la lògica de les lleis especials i tendeixen cap a les lleis consolidadores o els textos refosos. Això és, ambdós codis van venir a refondre en els respectius cossos normatius les diverses lleis especials anteriorment aprovades pel Parlament i ara la Llei 29/2002, de 30 de desembre, va més enllà i es proposa sistematitzar tota la normativa civil catalana en un sol text legal. Per a això, en especificar el concret procés d'elaboració, l'art. 6.4 de la Primera llei disposa que, si escau, cada llei de la sèrie contindrà una disposició final que autoritzi el govern a refondre, mitjançant Decret Legislatiu, les modificacions que en derivin amb les normes i les disposicions que restin sense alteració.

> Lògicament, el Llibre sisè relatiu a les obligacions i als contractes és el que ha de plantejar més dificultats en la seva elaboració, ja que aquesta és una matèria sobre la que, pràcticament, no hi ha hagut desenvolupament legislatiu i, a més, caldrà ajustar-la a unes bases de les obligacions contractuals, que el legislador estatal encara no ha definit.

Lluny, doncs, d'aquelles funcions constitucionals, el Codi simplement pretén ser una bona eina per a assolir un objectiu tan senzill, però alhora tan útil i cabdal pel futur del dret civil de Catalunya, com és garantir la seva efectiva aplicabilitat; i això per les raons següents:

a) La seva *utilitat*: un cop s'hagi completat la seva redacció, el Codi permetrà als operadors jurídics trobar reunit i sistematitzat tot el dret civil de Catalunya (dispers, actualment, en unes vint-i-cinc lleis) cosa que s'haurà de traduir, necessàriament, en una major freqüència en l'al·legació pels advocats i en l'aplicació judicial. Això vol dir també més *seguretat jurídica*.

b) La *simplificació i la unificació d'estil*: s'eviten reiteracions i remissions externes, que en canvi són imprescindibles quan la regulació resta escampada en lleis especials. Paral·lelament augmenta la qualitat de la llei.

c) La *reputació*: el dret codificat és percebut pels operadors jurídics i pels ciutadans en general com un dret més reputat que proporciona més anomenada a un ordenament.

Tots aquests avantatges no es veuen minvats, als menys substancialment, pel fet que el vigent sistema constitucional de distribució de competències no permeti que el Codi civil de Catalunya pugui arribar a abastar la totalitat de la matèria civil (recordem que l'art. 149.1.8a CE reserva a l'Estat, "en tot cas", la competència exclusiva sobre regles relatives a l'aplicació i eficàcia de les normes jurídiques, relacions jurídico-civils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i

instruments públics, bases de les obligacions contractuals i normes per a resoldre els conflictes de lleis).

En fi, salvant, és clar, quin sigui el concret desenvolupament que es faci de cada institució, la tècnica de la codificació civil, en ella mateixa considerada, no pot implicar la invasió de competències de l'Estat ni, menys encara, la vulneració de cap principi constitucional. Dit això, en aquest *paper* s'exposen els arguments amb els que pretenem demostrar la manca de fonamentació de la pretensió del govern de l'Estat de que es declari la inconstitucionalitat de la totalitat de la primera Llei del Codi civil de Catalunya, i se sosté que la Generalitat té plena competència per a aprovar el seu propi Codi civil.

2. El recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya: l'anacronisme de fonamentar la interpretació de l'art. 149.1.8a CE en els postulats decimonònics de la unificació civil

El 10 d'abril de 2003, el govern de l'Estat va interposar recurs d'inconstitucionalitat contra la totalitat de la Llei 29/2002, de 30 de desembre perquè entén que envaeix les seves competències i ha invocat, a més, l'aplicació de l'art. 161.2 CE, per a suspendre la seva vigència; subsidiàriament, el recurs l'ha adreçat també contra trenta-dos dels seus trenta-vuit articles del Llibre primer del Codi civil de Catalunya. En aquest treball em centraré, fonamentalment, en la **pretensió principal** de que es declari inconstitucional la totalitat de la llei, perquè en el fons, com deia, allò que el govern vol és negar la competència de la Generalitat per a aprovar un codi civil.

Substancialment, els arguments que el recurs fa servir per a fonamentar la manca de competència són dos:

- que la Llei 29/2002 determina la no aplicació, amb caràcter general, del dret de l'Estat a Catalunya, que en el propi recurs es qualifica de dret civil comú,

- que afecta *"las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas"*, que, recordem, és una matèria que l'art. 149.1, 8a CE atribueix en tot cas a la competència estatal.

D'aquí en treu la conclusió que la llei impugnada *"supone la implantación de un régimen distinto del actualmente vigente en el Código Civil en materia de derecho privado..."* i, més endavant, sorprenentment, afegeix que *"manifiesta una pretensión codificadora que resulta incompatible con la Constitucion, al tratar de establecer un régimen jurídico de Derecho civil para Cataluña completo e independiente del Derecho civil común estatal"*, com si no fos precisament això el que permet la pròpia Constitució (complet i independent, és clar, dins el marc competencial constitucionalment previst). Però és que, per contra, no hi ha res més oposat a l'estructuració jurídico-civil prevista a la vigent Constitució que l'esmentada *"[u]nidad del ordenamiento jurídico español"*, ja que aquest criteri de la unitat difícilment s'avé amb atorgar competència legislativa a la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar el dret civil català: s'oblida que l'art. 149.1.8a CE ha

constitucionalitzat la diversitat legislativa civil, amb el límit d'allò que en tot cas correspon a l'Estat.

De fet, si ens atenim al protagonisme que en aquest i en els anteriors recursos d'inconstitucionalitat contra lleis civils s'està atorgant al Codi civil espanyol, la conclusió que se'n desprèn és que el govern de l'Estat fa una lectura del text constitucional que segueix ancorada en una concepció de l'ordenament civil gairebé preconstitucional, com si l'etapa de les compilacions encara no hagués estat superada.

És cert que el recurs admet, al menys formalment, que la Constitució de 1978 va canviar les premisses que regien el dret civil anomenat comú i el propi dels anomenats territoris forals, però també ho és que, a la pràctica, es propugna una dràstica reducció de l'abast d'aquest model d'autonomia legislativa en base a una anacrònica interpretació històrica de l'art. 149.1.8a CE que pretén recolzar-se en la unitat legislativa perseguida pel moviment codificador decimonònic. D'aquí que una i altra vegada s'al·ludeixi a un pretès principi de *"la unidad del ordenamiento jurídico"* que avui no té cap base constitucional, al menys en el sentit que traspua tota la argumentació del recurs.

> Volent reforçar els arguments en favor d'aquesta pretesa unitat de l'ordenament, el recurs es remunta a la baixa edat mitjana, quan a la península i a Europa regia el *ius commune*. Aquesta cita històrica, però, més aviat denota una certa voluntat d'instrumentalització, ja que d'ella en treu la conclusió que, en virtut del Decret de Nova Planta, la funció de dret comú va passar a ser desenvolupada pel dret reial de Castella (Partidas i Nueva Recopilación) i és sabut que això no va ésser així, al menys pel dret civil de Catalunya, atès que en el Principat, a diferència del regne de Castella, no es va cosificar el dret romà en un text propi, sinó que el *ius commune*, tal com disposava la Constitució de Felip II a les Corts de Barcelona de 1599 (CiADC I, I, XXX, I), va seguir sent el supletori del català fins l'any 1960.

L'ideal unificador del segle XIX i la seva plasmació gairebé en totes les constitucions espanyoles de l'època, no pot servir de criteri interpretatiu de l'actual art. 149.1.8a CE, entre altres raons, fonamentalment, perquè aquest precepte dibuixa un sistema de distribució competencial que es contraposa a qualsevol pretensió unificadora. No s'ha d'oblidar, a més, que va ser precisament en l'època de la Restauració borbònica, quan la insistent reacció dels juristes catalans oposant-se a un Codi civil únic per a tota Espanya va portar, l'any 1889, a que el Codi civil acabés sent el del dret històric de Castella (seguint el model del Projecte de 1851) i que els territoris on subsistia l'anomenat dret foral el conservessin *"por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales"*. A més, l'objectiu d'un codi civil únic per a tot Espanya que exclogués l'aplicació dels drets territorials no s'arribà a aconseguir mai, si fem excepció d'algunes matèries concretes que van ser objecte de lleis especials d'aplicació general a tot Espanya, després la revolució de 1868, que va suposar el destronament d'Isabel II.

Però, fins i tot acceptant que recorri a la interpretació històrico-constitucional, el que més sorprèn del recurs és que passi totalment per alt qualsevol referència a la Constitució de la segona República (9 de desembre de 1931) que va ser la que va permetre que Catalunya recuperés la seva

capacitat legislativa perduda feia més de dos segles, oi més si tenim en compte que el seu article 15 és el que va servir de model per a la redacció del vigent art. 149.1.8a de la Constitució de 1978.

> L'art. 15 de la Constitució republicana, pel que fa a la legislació civil, senzillament atribuïa a l'Estat la competència sobre *"la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos personal, real y formal para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España"*. En la resta de matèries -afegia l'art. 16-, la legislació exclusiva i l'execució directa *"podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas... conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes"*. En aquesta línia l'art. 11 de l'Estatut de Catalunya de 1932 atribuí a la Generalitat "*la legislació exclusiva en matèria civil, llevat el que es disposa a l'art. 15 núm. 1 de la Constitució...*".

És innecessari recordar, per abastament conegut, que aquesta etapa d'autonomia legislativa va ser avortada pel règim franquista, que derogà l'Estatut i deixà sense efecte totes les lleis del Parlament de Catalunya i la doctrina del Tribunal de Cassació; això va abocar, irremeiablement, a la situació anterior a l'any 1931, és a dir, a la que dissenyà el Codi civil de 1889, tornant, doncs, a la provisionalitat del manteniment dels drets forals o especials, que perduraria fins el Decret Legislatiu 1836/1974 que aprovà el nou Títol Preliminar del Codi civil, que va venir a derogar l'originari art. 12.2 CC i, amb ell, l'expressió "*lo mantendrán por ahora*".

En l'interin, el Decret de 23 de maig de 1947, que tingué el seu origen en les conclusions del *Congreso Nacional de Derecho civil* celebrat a Saragossa l'octubre de 1946, havia canviat el sistema d'Apèndixs pel de les Compilacions, sense que això, però, suposés cap abandonament de la idea de refondre-les en un Codi civil únic per a tota Espanya. A partir d'aquí, la Comissió de juristes catalans redactà un text de 569 articles que va ésser revisat i finalment retallat fins als 344 articles, que són els que acabarien integrant la Llei de 20 de juliol de 1960. He fet aquest breu recorregut històric per destacar la conjuntura en que va ser aprovada la compilació i com, prescindint d'això, paradoxalment és el text que des del govern de l'Estat gairebé es pretén sacralitzar i convertir en l'eix sobre el que ha de girar la competència de la Generalitat en matèria civil. Per a això es fonamenta, però, en una interpretació esbiaixada i interessada, ja que la referència que l'art. 149.1.8a CE fa al *"allí donde existan"* no implica cap límit material de competències ni impedeix que es pugui anar més enllà de les normes compilades, sinó que tan sols constitueix un criteri per determinar quines Comunitats Autònomes poden legislar en matèria civil; l'únic límit que la Constitució posa pel desenvolupament legislatiu autonòmic és el de les matèries que "en tot cas" són competència de l'Estat. No és aquest, però, el criteri que segueix el Tribunal Constitucional, el qual, com més endavant referiré, sembla decantar-se també per una interpretació correctora (restrictiva) d'aquest precepte constitucional, que entén que la competència sobre desenvolupament dels anomenats drets forals (més correctament de les CCAA amb competència civil) exigeix una connexió institucional entre el dret compilat i la nova norma. Les compilacions es converteixen així en un límit material al desenvolupament legislatiu civil que la Constitució no preveu.

N'hi hauria d'haver prou amb una interpretació literal de l'art. 149.1.8a CE per comprovar que aquest perfila una estructura de l'ordenament civil de l'Estat i un àmbit competencial en matèria civil molt semblants, al menys des d'una perspectiva objectiva, a la que en el seu moment van

establir els arts. 15 i 16 de la Constitució republicana de 1931. Tal vegada la diferència més notable sigui la del nombre de Regions (Comunitats) autònomes que tenen reconeguda dita competència: els arts. 15 i 16 Constitució de 1931 l'atribuïen a *totes* les regions autònomes (d'acord, és clar, amb el que preveiessin els seus respectius Estatuts), mentre que la Constitució actual només la reconeix a les Comunitats en els territoris de les quals "*existan*" drets civils forals o especials. Amb això vull significar que el fet que ara l'art. 149.1.8a CE ubiqui la matèria civil dins el llistat de competències que corresponen a l'Estat no és argument suficient, com veurem tot seguit, per entendre que hi ha hagut un canvi de criteri, sinó que aquesta diferència sistemàtica es deu, senzillament, a que només les Comunitats Autònomes amb dret propi són competents per legislar en matèria civil.

> Que l'art. 16 de la Constitució de 1931 afirmés que la resta de matèries civils no atribuïdes a l'Estat "*[p]odrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas*", sense concretar –com, en canvi, sí concreta l'art. 149.1.8a CE- que aquesta competència és per a la "*conservacion, modificación y desarrollo*", no permet concloure que hi hagin diferències substancials entre el que disposen un i altre.

Precisament, el fet de que no totes les Comunitats Autònomes tinguessin dret civil propi és el que va determinar que la Constitució de 1978 ubiqués la matèria civil a l'art. 149 CE (que és on s'enumeren les competències de l'Estat), i no en l'art. 148 CE (que conté el llistat de competències de les CCAA), tot i que aquesta fóra la destinació més escaient. Això és el que ha donat peu a les interpretacions més restrictives per a la competència autonòmica i el que va portar a emprar la fórmula "*sin perjuicio del derecho civil foral o especial*", que òbviament pressuposa que les Comunitats amb dret civil propi poden tenir atribuïda estatutàriament aquesta competència.

El sistema constitucional espanyol s'estructura, doncs, en una pluralitat d'ordenaments civils amb àmbits d'aplicació propis i, per tant, no es pot dir que hi hagi una unitat de l'ordenament civil, més enllà de la que resulta de que tots ells estiguin a redós de la Constitució; però, com veiem, no és precisament aquest el concepte d'unitat de l'ordenament que és baralla en el recurs. El fet que el dret civil de l'Estat acompleixi la doble funció de ser d'*aplicació general i directa* (en allò que es refereix a les matèries excloses de la competència autonòmica que estan atribuïdes en tot cas a l'Estat) i d'*aplicació supletòria,* en la part encara no normada pel dret autonòmic en l'àmbit de la pròpia competència de la Generalitat, no s'ha d'identificar amb que regeixi un pretès principi d'unitat de l'ordenament jurídic espanyol, sinó tot el contrari: la supletorietat implica la heterointegració i aquesta es dóna, precisament, quan hi ha pluralitat legislativa.

Aquesta errònia concepció unitària de l'ordenament civil i la conseqüent interpretació restrictiva de la competència de la Generalitat en matèria civil es van traduir, ja fa uns quants anys, en la interposició per l'Estat de sengles recursos d'inconstitucionalitat contra la Llei 9/1987, de 25 de maig de successió intestada i contra la Llei 7/1991 de 27 d'abril, de filiacions, que van generar una forta reacció de les entitats jurídiques catalanes, conseqüència de la qual (i, sobre tot, no cal dir-ho, de la negociació política) va ser que el govern de l'Estat els retirés. A partir d'aleshores, es va entrar en l'etapa més prolífica en matèria de legislació civil per part del Parlament de Catalunya (des de l'any 1991 fins el 2002, s'han aprovat unes setze lleis civils) sense que hi hagués hagut cap tipus d'oposició per part de l'Estat; ara, però, en poc més d'un any, s'han interposat

tres recursos inconstitucionalitat: l'un contra tres dels articles de la *Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació;* un altre contra vuit articles de la *Llei 19/2002, de 5 de juliol de drets reals de garantia* i, darrerament, fa tan sols cinc mesos, contra la totalitat *Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya*, de bon tros, la més important de totes les lleis civils que ha aprovat el Parlament. Aquest últim, a més, té una especial significació, perquè, com deia, el que realment ve a qüestionar és que Catalunya pugui adoptar la tècnica d'un Codi civil. De fet la pròpia petició subsidiària persegueix indirectament la mateixa finalitat de deixar inoperant tota la llei per la via d'impugnar la pràctica totalitat dels articles que integren el llibre I, i, per si no havien quedat prou clares les seves intencions demana també la suspensió immediata de la seva vigència.

3. La jurisprudència del Tribunal Constitucional

Deia abans que el Tribunal Constitucional sembla haver-se decantat també per una interpretació força restrictiva de l'art. 149.1.8a CE, tot i que encara deixa un cert marge de flexibilitat, ja que la lectura que d'aquest precepte n'ha fet, per exemple la STC 88/1993 (FJ 1er) [que reitera després en la STC. 156/1993 de 6 maig] és que es tracta d'una norma que introdueix una *"garantia de la foralidad civil"*, en el sentit de que *"[l]a Constitución permite, así, que los derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto [...] de una acción legislativa que haga posible su crecimiento orgánico..."*, tot admetent, a més, que *"[n]o debe vincularse <u>rígidamente</u> al contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento"*. Fins aquí, aquest és un plantejament que, a primera vista, permet concloure que la competència autonòmica en matèria civil no té cap més límit que allò que, en tot cas, correspon a l'Estat; ara bé, observi's que quan afirma que la competència autonòmica no s'ha de vincular *rígidament* al contingut actual de la Compilació, ve a dir 'a contrario', que hom podria afirmar que hi ha un altre vinculació (no rígida), que el propi Tribunal Constitucional acaba identificant amb l'*exigència d'una connexió* entre les institucions compilades i la nova norma. Més específicament l'esmentada sentència 88/1993 afirma que:

> *"[C]abe, pues, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial* ***regulen instituciones conexas*** *con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral".*

Una conseqüència clara i immediata d'aquesta exigència és que quan més detallada sigui la regulació institucional que faci una determinada Compilació, més possibilitats de connexió hi hauran entre el dret que es desenvolupa i el compilat i, per tant, també més possibilitats d'acabar perfilant un ordenament civil complet. Aquesta és una interpretació que treu qualsevol transcendència al fet que la diferent extensió de cada compilació es tributària del concret moment polític del règim franquista en què va ser aprovada (és més completa, per exemple, la compilació navarresa, aprovada l'any 1973, quan la dictadura estava ja a les acaballes, que les primeres, com és la catalana aprovada el 1960).

> Una prova palpable del que aquesta interpretació restrictiva significa la trobem, precisament, en la part del recurs que demana que es declari inconstitucional gairebé tota la regulació de la prescripció (excepte

> els arts. 121-20, 121-21 i 121-22 que són, precisament, els que fixen els diferents terminis -decenal, triennal i anual-), això és les normes que més aviat toquen qüestions tangencials de la prescripció, com la ara necessitat que sigui al·legada, la possibilitat de renúncia, la interrupció, la suspensió, etc. És que no hi ha connexió entre els terminis de prescripció i la regulació del seu règim jurídic?.

Amb tot, cal ser optimistes i pensar que el criteri de les "*instituciones conexas*" és prou indeterminat com per considerar que es tracta només d'un expedient del que es val el Tribunal Constitucional per poder modular més àmpliament o més restrictivament, segons escaigui, la competència legislativa civil de cada concreta Comunitat Autònoma, i, aïlladament considerat, és prou flexible per admetre una competència de la Generalitat de Catalunya força àmplia. Aquest optimisme, però decau pel fet que, de moment, el Tribunal Constitucional no està deixant gaire camp per córrer, ja que a la fi adverteix que la indeterminació del concepte "institució connexa", "*[n]o significa claro està... una competencia legislativa ilimitada* ratione materiae *dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugna con los dispuesto en el art. 149.1.8a CE...*". Efectivament, la competència no és il·limitada, sinó que s'ha de mantenir dins els límits, tantes vegades citats, en les matèries que l'art. 149.1.8a CE atribueix en tot cas a la competència de l'Estat.

4. Constitucionalitat de la Primera Llei del Codi civil de Catalunya

La Llei 29/2002, de 30 de desembre té dos objectius, i així ho exposa el seu preàmbul: el primer és "*establir l'estructura, el contingut bàsic i el procediment de tramitació del Codi civil de Catalunya*" i, el segon "*aprovar el Llibre primer del Codi civil de Catalunya, titulat 'Disposicions generals', el qual, sens perjudici que es pugui ampliar en el futur, s'estructura ara en dos títols*". El recurs, en la seva petició principal, demana que la totalitat de la Llei sigui declarada inconstitucional; això és, hem d'entendre que es refereix tant a la part que basteix l'estructura del Codi, com a la que aprova el seu Llibre primer. Per tant, des del punt de vista de la petició d'inconstitucionalitat de tota la Llei, el debat es planteja en uns termes diferents que els de l'existència o no de connexió entre les institucions regulades i les contingudes en el dret anterior. L'Estat qüestiona que la Generalitat de Catalunya pugui emprar la tècnica d'un codi general, tot pressuposant, com s'ha vist, que amb l'aprovació del Codi es vulnera un suposat principi constitucional d'unitat legislativa que representa el Codi civil espanyol; a partir d'aquí, el recurs atribueix a la Primera Llei del Codi civil de Catalunya el pretès efecte negatiu d'eliminar qualsevulla possibilitat d'aplicació del Codi espanyol.

Sorprèn que una afirmació com aquesta es faci en el marc d'una Constitució que reconeix la competència legislativa de determinades comunitats autònomes per a legislar en matèria civil, ja que, en aquest context, la unitat només es pot admetre, si de cas, en el sentit que li dóna l'art. 147.1 CE quan afirma que els Estatuts d'autonomia (i per tant les normes que d'ells se'n deriven) són part integrant de l'ordenament jurídic de l'Estat, no en el paper de dret supletori que pugui correspondre al Codi Civil. La supletorietat és en si mateixa una eventualitat i l'aplicació de les normes amb aquest caràcter supletori depèn dels buits normatius que puguin existir. La Constitució vigent estructura un ordenament civil plural, integrat pel Codi civil i les lleis civils de

l'Estat i pels diversos conjunts normatius civils de cadascuna de les autonomies, en pla d'igualtat amb el primer i amb els seus propis principis i àmbit d'aplicació. És en aquest sentit, doncs, que s'han d'entendre les expressions "sub-ordenaments" o "subsistemes" i per tant no té cap fonament constitucional emparar-se en una pretesa unitat de l'ordenament i en la prevalència del codi espanyol.

Per reforçar aquesta idea d'unitat, el recurs emfasitza sobre l'existència d'un *sistema global*, que comprèn les normes que no pertanyen a un subsistema, és a dir, les que regulen la matèria que és competència exclusiva de l'Estat (en tot cas), que aquí tampoc no discutim. De fet l'aplicació de les normes que conformen aquest anomenat sistema global no és una qüestió de supletorietat, sinó de dret primerament aplicable. En efecte, el Codi català, per definició, no pretén ni pot disciplinar aquestes matèries ni, de fet, cap de les seves disposicions exclou l'aplicació de les normes del Codi civil espanyol que, anant més enllà del dret civil, pertanyen a allò que prodría anomenar-se ordenament jurídic espanyol com un tot (com pot ser per exemple l'art. 2 CC en relació amb la derogació i la irretroactivitat; l'art. 3 CC en relació amb els criteris generals d'interpretació de les normes jurídiques; l'art. 4 CC respecte dels límits per a l'aplicació analògica, etc).

> El fonament per a sostenir la insconstitucionalitat de la major part de les disposicons preliminars és que aquestes envaïen la competència exclusiva de l'Estat sobre *"[...] reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas civiles[...]"*. No és aquest el lloc, ni el moment, per a analitzar la manca de solidesa d'aquesta fonamentació, però no em puc estar de dir que el context és clar: les normes sobre aplicació i interpretació que es contenen en el codi català tenen per objecte exclusivament el dret civil de Catalunya.

En qualsevol cas, el tenor dels set articles que componen la Primera Llei del Codi civil de Catalunya, difícilment permet concloure que tota la Llei és inconstitucional; d'una banda, si hom té en compte que el seu objecte és establir l'estructura, la sistemàtica i aprovar-ne el llibre primer, no veiem com una estructura bàsica, ni menys encara la sistemàtica emprada, poden infringir les competències de l'Estat en matèria civil; el lògic fóra que, en el seu cas, la inconstitucionalitat es prediqués del contingut (i de moment, l'únic contingut normativament detallat que es coneix és el del Llibre primer). Atès que no s'ha produït encara el desenvolupament normatiu concret de la resta de llibres, no hi cap una valoració de la constitucionalitat dels futurs continguts.

Malgrat la pretensió de que es declari inconstitucional tota la llei, paradoxalment, el recurs no cita, ni una sola vegada, cap dels preceptes de la Llei 29/2002, sinó que es fonamenta exclusivament en els del Llibre Primer del Codi civil de Catalunya que ha estat aprovat, això sí, per l'art. 7: concretament, els arguments són, d'una banda, que el codi català no crida *expressis verbis* al Codi civil espanyol com a supletori (art. 111-5), i, d'una altra, que els principis generals del dret han passat a integrar-se dins les fonts del dret civil català (art. 111-1 i 111-5), assumint la funció de suplir les seves deficiències o llacunes, cosa que comporta l'exclusió de la legislació estatal. Però en aquest punt, cal insistir novament en que el Llibre primer del Codi no estableix res diferent del que ja disposava la DF 4a de la Compilació; és més, encara que hom admetés la inconstitucionalitat d'aquestes normes, això no pot repercutir en la inconstitucionalitat de tota la Primera llei. El Codi civil de Catalunya, abstractament considerat, no pot ser considerat

inconstitucional pel sol fet que els principis generals del dret propi s'incloguin, ara expressament, entre les fonts del dret, sinó que en el cas hipotètic que es considerés que aquelles normes que els regulen no s'ajusten a les previsions constitucionals sobre la competència de la Generalitat en matèria civil, n'hi hauria d'haver prou amb impugnar els preceptes concrets del Llibre primer que s'hi refereixen.

> Això és el que pretén la petició subsidiària en demanar, com deia, que es declari la inconstitucionalitat de 32 dels 38 articles que integren el llibre primer del Codi, a saber: l'art. 111-1 apartat 2n, en relació amb el sistema de fonts del dret; l'art. 111-4 que estableix el caràcter de dret comú del propi codi i per connexió l'art. 111-5, sobre la preferència del dret civil de Catalunya i el paper de filtre que exerceixen el principis generals del dret propi quan s'ha d'acudir a l'aplicació del dret supletori; l'art. 111-6, que positivitza el principi de llibertat civil, l'art. 111-7 sobre el principi de la bona fe i la honradesa en els tractes; i, l'art. 111-9 sobre l'equitat; tot això, a banda, és clar, de que també demana la inconstitucionalitat del Títol II, sobre la prescripció i la caducitat (llevat els tres articles sobre terminis).

És molt simptomàtic, doncs, que la petició principal sigui la inconstitucionalitat de tota la Llei i que la subsidiària afecti gairebé el vuitanta cinc per cent dels articles, evidenciant així una clara voluntat de deixar sense contingut allò que realment ha de donar coherència i unitat al Codi i a tot el dret civil de Catalunya: les disposicions preliminars. Precisament, l'argument principal en el qual se sustenten amdues pretensions és –insistim- l'atribució al Codi espanyol d'un un rang que podríem catalogar de quasi-constitucional, en la mesura que el recorrent el considera una manifestació de la *"unidad básica del derecho civil español"* de la que només es poden excepcionar la conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils forals *"[s]in que ello pueda suponer nunca la creación de un sistema jurídico autónomo que inadmita qualquier grado de supletoriedad estatal"*. El recurs parteix d'una errònia interpretació de l'art. 149.1.8a. CE, que es fonamenta en la concepció del Codi civil espanyol com a *"derecho común en el ámbito del Derecho privado en cualquier parte del territorio nacional"*, quan la realitat és que l'única norma constitucional que li reserva algun paper, al Codi espanyol (la supletorietat) és l'art. 149.3 CE. Certament, podem dir que el Codi espanyol està vigent a tot l'Estat com a dret supletori (cosa que és diferent de la seva aplicabilitat) i també en la part que és d'aplicació directa. Dit en altres paraules, no es pot oblidar que, precisament, allò que permet la Constitució és la creació de sistemes jurídics autònoms i que l'aplicació supletòria només depèn de la major o menor complitud de cadascun dels ordenaments que es completa. N'hi ha prou, doncs, amb llegir l'art. 111-5 CCCat per adonar-se'n que no vulnera cap precepte constitucional, no només perquè no exclou l'aplicació supletòria del Codi espanyol, sinó perquè, sota la fórmula genèrica de dret supletori, hi queda plenament subsumit.

En aquesta mateixa línia, l'art. 111-4 CCCat, segons el qual el Codi civil de Catalunya és dret comú a Catalunya, tampoc no depassa les previsions constitucionals sobre competència de la Generalitat en matèria civil, ans al contrari es limita a reproduir el que ja havia afirmat la sentència del Tribunal Suprem de 28 de juny de 1968, en resoldre que el dret civil català és, pels catalans, el seu dret comú i, consegüentment, que s'ha d'aplicar de manera preferent al Codi espanyol, fins i tot en la supletoritetat del Codi de comerç. De fet, això es veu refermat, en certa mesura, per l'art. 26.1 EAC, que disposa:

> *"[E]n matèria de la competència exclusiva de la Generalitat, el dret català és aplicable en el seu territori amb preferència a qualsevol altre".*

Des d'aquesta perspectiva, i vistes les anteriors argumentacions, sobra dir que l'elecció de la tècnica d'un codi civil per a Catalunya no pot suposar, per si sola, cap invasió de les competències de l'Estat, sinó que la inconstitucionalitat només s'haurà de predicar, si escau, dels preceptes concrets que, en regular les concretes institucions envaeixin els límits assenyalats a l'art. 149.1.8a CE (i l'art. 9.2 EAC). És més, la pròpia circumstància de que en la petició subsidiària d'inconstitucionalitat, s'excloguin encara que només sigui sis preceptes de la impugnació abona aquesta interpretació i constitueix un sòlid argument per a que sigui desestimada la pretensió d'insconstitucionalitat de tota la llei.

Atribuir al Codi civil espanyol la funció de ser un límit competencial que impedeixi que la Generalitat de Catalunya pugui aprovar un Codi civil propi no té suport normatiu; ni la Constitució no conté cap previsió en aquest sentit, ni reserva cap paper específic al codi espanyol, més enllà de considerar-lo, com la resta del dret estatal, d'aplicació supletòria i sens perjudici, és clar, dels preceptes que són d'aplicació directa. En qualsevol cas, la supletorietat del dret estatal i, per tant, del codi espanyol, queda perfectament preservada i garantida per l'art. 111-5 CCCat, que disposa:

> *"Les disposicions del dret civil de Catalunya s'apliquen amb preferència a qualssevol altres. El dret supletori només regeix en la mesura que no s'oposa a les disposicions del dret civil de Catalunya o als principis generals que l'informen".*

Però no és només que l'esmentat art. 111-5 CCcat es mantingui escrupolosament dins els límits competencials previstos a la Constitució, sinó que reprodueix la mateixa regla que fins ara contenia la DF 4a. Senzillament, allà on la DF 4a CDCC es remetia al *"Codi civil* [espanyol] *i altres lleis estatals"*, l'art. 111-5 CCCat ho ha substituït, genèricament, pel *"dret supletori"*. Comparem-lo, sino amb la redacció de la DF 4a segons la qual,

> *"[...]en el que no preveuen les disposicions del dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de caràcter civil, en la mesura que no s'oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l'ordenament jurídic català"*

D'això se'n fa ressò també el preàmbul quan afirma que el Títol primer recull i sistematitza els preceptes fins ara continguts en el Títol Preliminar i en les Disposicions Addicionals segona i quarta de la Compilació. Per tant, no és cert que comporti *"[l]a creación de un sistema jurídico autónomo que inadmita cualquier grado de supletoriedad estatal"*, sinó que són molts, encara, els supòsits en els que el dret estatal, i molt particularment el Codi civil espanyol, ha d'entrar com a supletori del català. Això no treu que, tenint en compte que entre les aspiracions del legislador català hi ha la d'anar omplint totes les llacunes derivades de la manca de desenvolupament legislatiu, s'arribi finalment a excloure totalment l'aplicació del dret supletori (en allò que la Generalitat no té competència, el dret estatal s'aplicarà directament, no pas supletòriament). És a dir, per la via d'assolir el màxim grau de desenvolupament, el dret català podria arribar a cobrir totes les matèries civils sobre les que té competència, fent innecessària l'aplicació del dret

supletori, la qual cosa en cap cas no afecta l'aplicació general i directa de les normes que regulen matèries civils que són competència de l'Estat.

Així doncs, descartat que el Codi espanyol sigui un exponent del principi de la unitat legislativa, només ens resta analitzar l'argument que basa la pretensió d'inconstitucionalitat en el fet que l'art. 111-1 inclogui els principis generals dins les fonts del dret civil català, considerant-la una norma de tancament que impedeix l'aplicació supletòria del Codi civil espanyol. Entenc que aquest precepte tampoc incorre en inconstitucionalitat ja que no diu res que no digués ja la Compilació. L'esmentada DF 4a en afirmar que el Codi civil espanyol i les altres lleis estatals de caràcter civil només s'aplicaven en la mesura que no s'oposessin al dret català o als principis generals que informen l'ordenament jurídic català, de fet, ja estava admetent que, a la Compilació, els principis generals eren font del dret. L'única referència que expressament no contenia aquella DF 4a era la jerarquització del costum dins les fonts del dret civil català, i resulta que ara que s'incorpora expressament a l'art. 111-2.2 CCCat, aquest és dels pocs preceptes que no ha estat objecte d'impugnació. Tota una paradoxa.

Però el més greu és que, el recurs contingui omissions molt flagrants: una, que ja he esmentat, es que, no al·ludeix ni una sola vegada a la Constitució republicana que és l'antecedent immediat del vigent art. 149.1.8a CE que dóna bons arguments en contra de l'estesa interpretació restrictiva; i una altra que, tot i que el debat argumentatiu sobre la pretesa inconstitucionalitat se centra en la regulació de les fonts del dret que fa el Codi civil de Catalunya, el recurs no fa ni una sola referència a que la competència de la Generalitat per a fixar el sistema de fonts del dret propi resulta de l'art. 149.1.8a CE, segons el qual, en la seva determinació l'Estat ha de respectar *"les normes de dret foral o especial"* i de l'art. 26.e EAC que reitera aquesta mateixa norma establint que "*En la determinació de les fonts del dret civil, l'Estat respectarà les normes del dret civil català*". En fi, el dret civil de Catalunya no només pot tenir el seu propi sistema de fonts, sinó que mitjançant la tècnica codificadora pot legitimament pretendre situar-se –encara que de moment sigui només d'una manera gairebé formal - entre els ordenaments plenament normalitzats. Amb la Constitució a la ma, no trobem cap raó perquè això no pugui ser així, ans el contrari, ens reconeix aquest dret.